

1500521-25.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... processado na adolescência por receptação e tráfico e depois de adulto por tráfico. Em relação aos fatos, negou sua autoria, esclarecendo que a droga foi forjada em sua residência. Ponderou que foi pego tomando banho e que em momento algum saiu correndo da polícia. Esclareceu que os policiais não tinham mandado e que forjaram as drogas em sua residência. Asseverou que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500521-25.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500521-25.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2096104/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 17227076 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 790/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2096104 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 790/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS FABRICIO BRIZACO FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

DENIS FABRICIO BRIZACO FONSECA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 08 de abril de 2021, por volta das 10 horas, na Rua Quinze, n.º 110, Pinus do Iriguassu II, nesta cidade e Comarca de Caçapava, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, 65 (sessenta e cinco) porções de cocaína e 32 (trinta e duas) porções de

Cannabis sativa L. (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 20/21, laudo de constatação provisória a fls. 29/32.

O réu constituiu defensor e apresentou defesa prévia (fls. 83/90), sendo recebida a denúncia em 20/07/21 (fls. 116/118).

Durante a instrução, realizada virtualmente, conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/22, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, três de defesa, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação do réu, enquanto a defesa requereu sua absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, afasto a alegação de ilicitude da prova obtida sem a expedição de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, em se tratando de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mitigada fica a inviolabilidade de domicílio, em atenção à própria norma constitucional, que preconiza que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)", de modo que aquele que tem em depósito drogas em sua residência, com nítida finalidade mercantil, tal como o acusado, encontra-se em situação flagrancial permissiva do ingresso no imóvel, inclusive sem autorização do morador ou mandado judicial.

De todo modo, é evidente que os elementos fáticos autorizavam a afirmação de justa causa pelos policiais para o ingresso na residência do réu sem mandado, pois havia informações e denúncias de que o acusado havia acabado de sair da biqueira da rua 6 com a chegada da polícia. Ademais, os agentes civis foram até o local mencionado para verificar referida informação e viram o acusado em atitude que lhes pareceu suspeita, tendo em vista que, ao visualizar a viatura policial, ele saiu correndo para o interior do imóvel e simulou estar tomando banho.

Afastada a preliminar, no mérito, a presente ação penal merece ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21), Laudo de Constatação Provisória (fls. 29/32), Exame Químico-Toxicológico (fls. 108/110) e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, o réu DENIS FABRICIO BRIZACO FONSECA disse que tem 27 anos, é solteiro, tem uma filha, trabalha de cuidador de idoso, já foi processado na adolescência por receptação e tráfico e depois de adulto por tráfico. Em relação aos fatos, negou sua autoria, esclarecendo que a droga foi forjada em sua residência. Ponderou que foi pego tomando banho e que em momento algum saiu correndo da polícia. Esclareceu que os policiais não tinham mandado e que forjaram as drogas em sua residência. Asseverou que os policiais civis não encontraram nada e, depois de vistoriada a casa pelo BAEP, o canil chegou e apresentou as drogas, mas em momento algum acompanhou as diligências. Quanto ao dinheiro, admitiu sua propriedade, pois é usuário de maconha e havia farelo de maconha no dinheiro e, por isso, o numerário acabou sendo localizado pelo cachorro. Reafirmou que não acompanhou as buscas no imóvel e que a droga foi forjada, acreditando que isso se deu por ser morador do Pinus. Disse que trabalha cuidando de seu avô e que ganha novecentos e poucos reais por essa atividade.

A negativa de autoria do acusado, além de vaga e imprecisa, contrasta com os demais elementos de prova, especialmente com a firme e uníssona narrativa dos policiais civis em juízo.

Com efeito, o investigador de polícia MARCELO CARDOSO SILVA, em juízo, disse que, no dia dos fatos, deflagraram operação para dar cumprimento a mandados de busca e prisão referentes à investigação de tráfico nos bairro. No curso das diligências, receberam a informação de que o réu, conhecido como DENÃO, estava em uma árvore na biqueira da Rua 6 e depois foi para sua casa na rua XV. Após isso, diligenciaram na residência do acusado, onde flagraram o réu no quintal, que saiu correndo para o interior do imóvel ao notar a presença da polícia, simulando estar tomando banho no

banheiro. Em buscas no banheiro nada foi encontrado. Aos ser indagado sobre a venda de drogas na biqueira da árvore, Denis no início negou, mas, com a presença do canil da Polícia militar, foram apontadas e localizadas pelo cachorro, na parte externa da residência, no quintal, 65 porções de cocaína e trinta e pouco de maconha. Em outro cômodo, em uma caixa apontada pelo cachorro, encontraram quantia em dinheiro com resquícios. Por isso, o réu foi conduzido ao DP. O declarante conhecia o réu anteriormente por suas passagens na adolescência e na maioridade por tráfico. Não possuía nada contra o réu, apesar do depoente saber de seu envolvimento com o tráfico. O réu negou a propriedade das drogas. Ingressaram por volta das 10:00 hs da manhã na residência do réu e não tinham mandado específico para o local. A diligência na casa do réu se deu em cima da denúncia e da fundada suspeita de correr pra dentro da residência ao notar a presença da polícia. A biqueira da Rua da Arvore é próxima à casa do réu. Além do réu, havia sua esposa no local e ninguém apareceu na residência durante as diligências no imóvel. Em correspondência de entendimento, sob o crivo do contraditório, o investigador de polícia DAVID SANTOS DE OLIVEIRA confirmou que, durante operação deflagrada com outras forças de segurança para diversas incursões no Pinus I e II, ao adentrarem no bairro, viram várias pessoas no ponto de vendas de drogas, que saíram correndo com a chegada da polícia, dentre as quais o acusado, que correu em direção a sua residência, que fica próxima ao ponto de drogas. No entanto, ao chegarem na residência, Denis estava do lado de fora da casa e adentrou o imóvel ao notar a presença da polícia, simulando estar tomando banho. Com o auxílio do canil do BAEP, no lado externo, foram encontradas as drogas apreendidas nos autos, cuja propriedade foi assumida informalmente pelo réu. O réu possui o apelido de DENÃO e é conhecido da polícia desde 2011 por tráfico e receptação. No dia, chegaram várias denúncias de que Denis saiu do ponto de drogas e foi para sua casa. O depoente não tem nada contra a pessoa do réu. O depoente não presenciou o encontro de drogas para não tirar a atenção do cachorro da PM. Também foi localizada uma quantidade de dinheiro. Foram localizadas maconha e cocaína. Não possuíam mandado de busca contra o réu, mas possuíam a informação de que ele era o gerente do tráfico; além disso, o acusado correu para casa com a chegada da polícia no bairro; por fim, o réu correu para o interior do imóvel com a aproximação da polícia.

A informante ELIANE ASSIS SEIXAS disse que conhece o réu há muito tempo e que o considera como filho. Sabe que Denis teve problema com a polícia, mas atesta que de uns anos para cá "ele melhorou bem". Nunca o viu fazendo bagunça na rua.

A testemunha de defesa BRUNO ROBERTO SEIXAS, em juízo, disse que tem contato diário com o réu e esclarece que nunca o viu trabalhando no tráfico.

PÂMELA THAIS DA SILVA, informante da defesa, disse que é ex-mulher do réu, porém, esclarece que ele é de boa índole, bom pai e que nunca tiveram problema. Sabe que Denis teve problemas no passado com a polícia. Disse que estava na residência no dia da incursão policial e nada de ilícito foi encontrado no interior e exterior do imóvel pela Polícia Civil. Tampouco os cachorros do BAEP encontraram algo de ilícito em sua residência. Disse que foi o policial do BAEP que forjou as drogas no imóvel, pois não tinha nada em sua casa. Seu ex-marido estava tomando banho, pois ele ia trabalhar.

Pois bem!

Em que pese a versão de DENIS e de sua ex-esposa PÂMELA, não há nenhum indício de que os agentes da lei MARCELO CARDOSO e DAVID SANTOS estejam mentindo com o propósito de prejudicar o acusado.

Ademais, as circunstâncias da prisão de DENIS, precedida de informações de que ele havia acabado de sair da Biqueira da Árvore, seguida de sua tentativa de fuga, associados ao encontro de variadas drogas e dinheiro são indicativos verossímeis de que o réu estava envolvido com o tráfico e que os entorpecentes apreendidos em sua residência estavam destinados para este fim.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais,

indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

A estratégia do acusado evidentemente foi procurar desqualificar e desacreditar a versão dos agentes estatais. No entanto, não se afigura verossímil a invenção de uma narrativa tendenciosa direcionada à imputação leviana de um crime a pessoa inocente.

Outrossim, não é crível que os policiais civis em questão saíssem a esmo, forjando drogas, em casa habitada, simplesmente para prejudicar o acusado, pois sabiam que poderiam ser desmentidos por seus moradores e/ou vizinhos.

Ainda, fosse verdadeira a versão do acusado estar-se-ia legitimando uma farsa engendrada pelos investigadores de polícia, com a cumplicidade da Polícia Militar, todos mentindo e colocando suas carreiras em risco sem nenhuma razão legítima comprovada.

Lado outro, as testemunhas de defesa ELIANE e BRUNO, pessoas próximas e do convívio estreito do réu, apenas atestaram sua boa conduta, o que é insuficiente para afastar a acusação de tráfico.

De seu turno, no tocante a PÂMELA, ex-esposa do acusado, é evidente seu interesse em ajudar o marido e pai de sua filha, razão pela qual seu depoimento deve ser visto com ressalvas.

Considere-se, por fim, que "[...] não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]" (RT 729/542).

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade, bem como o dolo de traficar, impõe-se a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, respeitado o sistema trifásico, há de ser considerada a expressiva quantidade de entorpecentes (65 porções de cocaína e 32 porções de Cannabis sativa L), bem como a natureza nociva da cocaína, Assim, sendo desfavoráveis tais circunstâncias, a pena base deve ser exasperada em 1/6 (um sexto), totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, além 583 dias-multa.

Anote-se que, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

Na segunda fase, ausentes atenuantes.

Incide a circunstância agravante da reincidência específica, uma vez que o acusado foi condenado em definitivo por tráfico de drogas nos autos de nº 2635-

20.2015.8.26.0101 (fls. 160/161). Além do mais, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, não se podendo negar que o acusado se valeu de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem estar da coletividade. Desse modo, majoro as pensa em 1/3 (um terço), resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Com efeito, cuida-se de réu reincidente específico (autos nº 2635-20.2015.8.26.0101 - fls. 160/161), o que, por óbvio, comprova tratar-se de pessoa dedicada ao crime.

Assim, descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Não se olvide que o reconhecimento do tráfico privilegiado somente se aplica ao novato, aquele que, sendo primário e sem antecedentes criminais, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, evidentemente, não se cuida o acusado DENIS.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica dos réus.

Deverá o réu, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.654/07, iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, que é o mais adequado diante da gravidade do delito, assemelhado a hediondo. Ademais, conforme acima fundamentado, o acusado é reincidente específico (autos nº 2635-20.2015.8.26.0101 - fls. 160/161), o que reforça a necessidade de fixação de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, uma vez que o réu não preenche os pressupostos legais, notadamente em face da insuficiência da medida, já que a pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão e por se tratar de réu portador de reincidência específica (autos nº 2635-20.2015.8.26.0101 - fls. 160/161).

No sentido de que eventual substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se revela suficiente para punir e prevenir condutas que tais, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ASSOCIAÇÃO.

CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DIVERSIDADE IMPOSSIBILIDADE. I. A caracterização do crime de associação permanente para o tráfico de entorpecentes, enquanto requisita o reexame do conjunto da prova é inadequado ao âmbito angusto do habeas corpus. 2. A consideração do magistrado sentenciante na individualização da pena de que o paciente 'pertence a uma hierarquia superior no tráfico de entorpecentes, coordenando os outros dois acusados na distribuição da droga na Região', para além de lhe serem desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, não são circunstâncias estranhas ao elenco do artigo 59 do Código Penal, sendo bastante à exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A substituição da pena privativa de liberdade pela sanção restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal, enquanto resposta penal em natureza, está subordinada, inarredavelmente, ao princípio da suficiência. 4. Concluindo a Corte Estadual pela necessidade do réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, à luz de motivação excludente, em natureza, das condições da pena restritiva de direito, também recusa a substituição da pena privativa de liberdade, por necessária consequência, ante sua insuficiência. 5. Ordem parcialmente conhecida e denegada" (STJ, HC 31628/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j . 04/09/2007, DJe 04/08/2008) - destaque nosso.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu DENIS FABRICIO BRIZACO FONSECA às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 777 dias-multa, no menor valor unitário, por infração ao artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, "b" do Código Penal e no artigo 62 da lei 11.343/06, o perdimento, em favor da União, de eventual importância em dinheiro apreendida em poder do réu, porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc.

III, da Constituição Federal; (iv) notifiquem-se os réus para pagamento da pena de multa; (v) se o caso, expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada nos autos para defesa do réu, observados os termos do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública.

P.R.I.C.

Caçapava, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA